

Bogotá D.C., Febrero 21 de 2007.

Doctora

SANDRA FORERO

Gerente

Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Consulta: No. 0031 – 2007

Referencia: Contratos Interadministrativos.

Respetada Doctora Forero, un cordial saludo.

De conformidad con la solicitud expresa de la Doctora Beatriz Uribe, referente a la revisión y proyección de un concepto atinente a la regulación de los Contratos Interadministrativos y el enfoque dado a los mismos en el nuevo proyecto de Ley sobre Contratación Administrativa, a continuación encontrará unas precisiones sobre el tema:

Límites a la Contratación Interadministrativa:

La Ley 80 de 1993, consagra como regla general la obligación de seleccionar a los contratistas del Estado a través de licitación o concurso público, no obstante, también contempla la posibilidad de contratar a través de convenios interadministrativos, es decir, aquellos que celebren entre sí en forma directa las entidades a que se refiere el artículo 2o de la Ley 80 de 1993, con excepción de los contratos de seguro, encargo fiduciario y fiducia pública. (Art. 24, numeral 1o, Literal C de la Ley 80 de 1993 y Art. 7 Decreto Reglamentario 855 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de contratación directa).

En el contexto normativo antes anotado, dentro de las modalidades de la contratación directa, se configuran estos tipos de convenios en un régimen excepcional al deber de formular públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable.

En cuanto a los Convenios Interadministrativos, las reglas del Estatuto de Contratación vigentes, disponen:

- Que se celebrarán directamente, es decir, prescindiendo de licitación o concurso públicos, excepto los de seguro, encargo fiduciario y fiducia pública (Artículos 24º, numeral 1o, literal C. y 32º de la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 855 de 1994, artículo 7º.).
- Que en estos se puede prescindir de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales, tales como la de caducidad, las de interpretación, modificación y terminación unilaterales y la de reversión (Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º numeral 2o. y parágrafo).
- Que no son obligatorias las garantías que avalan la seriedad de los ofrecimientos hechos o el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato (Artículo 25º numeral 19 de la Ley 80 de 1993).
- Cuando fuere el caso y de conformidad con lo dispuesto por las normas orgánicas de presupuesto serán objeto del correspondiente registro presupuestal (Artículo 7º. D.R. 855/94), norma que también contempla la exigencia de publicación de estos convenios.
- No impiden el ejercicio del control por parte de las autoridades competentes del comportamiento de los servidores públicos que hayan intervenido en dichos procedimientos y en la celebración y ejecución del contrato (Parágrafo 1o del Artículo 24º de la Ley 80 de 1993).
- Si bien las entidades estatales pueden contratar directamente, el jefe o representante de la

entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la ley 80 de 1993.

- Para la celebración de estos convenios, como vimos, previstos en el literal c del numeral 1o del artículo 24º de la Ley 80 de 1993, no se requiere de la obtención previa de ofertas, como así lo prevé el artículo 3º del Decreto Reglamentario 855 de 1994, que en lo que tiene que ver con contratación directa limitó esta exigencia a los contratos a que se refieren los literales a) y d) del numeral 1o. del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y a las situaciones contempladas en el artículo 12º del Decreto en cita.
- Para la celebración de los contratos de que trata el Decreto 855 de 1994, entre ellos los interadministrativos, el artículo 16º del mismo dispone que, *“siempre que existan igualdad de condiciones, las entidades estatales podrán seleccionar preferentemente, a las cooperativas, microempresas, fundaciones, juntas de acción comunal, y en general, a entidades de naturaleza similar del lugar donde deba ejecutarse el contrato”*.

Como consecuencia de lo anterior, tenemos que los contratos interadministrativos se rigen esencialmente por las normas pertinentes del derecho privado (artículo 13º, Ley 80 de 1993), no obstante se encuentran sujetos a los principios generales (transparencia, economía y responsabilidad) y a los deberes de la contratación pública (selección pública y publicidad), de los cuales, no puede sustraerse el ente estatal contratante; además de tener como limitante, dentro del marco de la autonomía de la voluntad, el deber de consultar y obedecer al cumplimiento de los fines del Estado.

En el caso del deber de aplicar la selección objetiva del contratista, el cual hace parte de la concreción y desarrollo del Principio de Transparencia, se busca garantizar que la elección de aquel, se haga de manera imparcial, objetiva y en igualdad de condiciones (escogencia del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés o, cualquier clase de motivación subjetiva).

Para el caso de los convenios interadministrativos, si bien no se requiere como antes lo vimos, de la obtención previa de ofertas, el jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, lo cual en armonía con los demás principios que rigen las actuaciones contractuales de las entidades estatales, entre ellos el de la publicidad, debe velar por que se respete la igualdad de condiciones en la selección de las entidades de que trata el artículo 16º del Decreto 855 de 1994, para la celebración de los convenios interadministrativos.

No obstante lo anterior, estos contratos se han convertido en un instrumento para eludir los procedimientos de selección objetiva, privando a los particulares de la posibilidad de participar en el proceso licitatorio, abriendo la puerta para que las entidades públicas entreguen recursos sin ningún tipo de control o auditoria, sin divulgar los convenios y generando la desviación de recursos con los costos sociales y económicos que ello implica.

Si bien, las razones que respaldan la suscripción de los mencionados convenios han sido cimentadas por el interés de hacer mas *“sencilla”* y eficiente la contratación, y fue consagrada en desarrollo de la autonomía legislativa, sin contrariar la Carta Política, la disposición que consagra dicha categoría al no estar respaldada en una justificación más razonable que el interés de facilitar el proceso contractual (¿agilidad en detrimento de la transparencia?), puede estar desconociendo los principios de igualdad de oportunidades, moralidad, imparcialidad y publicidad, pues aunque una de las funciones más relevantes de la contratación pública se centra en la eficiencia y en la satisfacción de los intereses públicos ciudadanos respecto de la provisión de bienes y servicios públicos, ésto no sólo debe observarse en la facilidad para contratar sino en la manera como se contribuye a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

La exclusión de particulares para contratar al no garantizarse el respeto a la igualdad de condiciones, que en la práctica genera este tipo de convenio, amenaza tal propósito, pues no existe una verdadera razón de conveniencia para impedir el desarrollo de la competencia y la elección de la propuesta con las condiciones más favorables, afectando la realización del interés público y de los fines estatales.

Frente a esta situación, los diferentes proyectos de Ley modificatorios de la Ley 80 de 1993, que se han radicado en el Congreso de la República, han intentado en sus primeras fases eliminar el foco de corrupción o deslealtad que se podría estar creando con esta contratación, con propuestas como la posibilidad de contratar sólo ante la inexistencia de particulares que suministren los bienes o servicios o con la exclusión expresa de las universidades y de las cooperativas, tratándose de la celebración de los convenios interadministrativos.

Sin embargo, a lo largo de los debates se ha hundido tal iniciativa, por considerarse que su inclusión haría desaparecer una fuente importante de generación de recursos para las universidades, que han demostrado (según se ha argumentado sin presentar indicadores que respalden esta posición) una ejecución eficiente de los contratos, pero no se ha puesto de relieve que lo que se busca no es desconocer la buena labor que pueden desarrollar estas entidades, sino darle preponderancia al interés general, en busca de garantizar la igualdad de condiciones y abrirse la posibilidad de elegir al contratista que sea más idóneo y que presente las mejores condiciones para la contratación sin excluir a los particulares de la posibilidad de concursar.

Lo anterior no debe ser analizado desde el extremo de excluir a las cooperativas y a las universidades públicas de la oportunidad de celebrar convenios interadministrativos, sino reiteramos, en procura de garantizar la oportunidad de otorgar iguales condiciones con relación a los privados tendiente a lograr una competencia equitativa y realización del principio de selección objetiva.

Ahora bien, el proyecto de ley que se tramita en la actualidad en la Cámara de Representantes (Proyecto de Ley 0057 de 2006/Cámara), al cual sólo le falta un debate, intenta modificar sin demasiado éxito la actual regulación, al disponer que la contratación interadministrativa solo puede darse cuando las obligaciones derivadas de la misma tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos; situación que a pesar de generar una limitante, no soluciona de manera categórica el problema de fondo, pues lo que determina es una serie de discusiones sobre su interpretación en relación son el objeto y la misión de las universidades, que en todo caso podría dejar por *“fuera de concurso”* a otros particulares interesados en contratar.

En este punto, debe pensarse que la disposición final que quede consignada en el novísimo Estatuto de Contratación, no debe propender por favorecer a unos u otros, sino buscar que los principios generales de equidad en las oportunidades, sea ejecutado de manera cierta, y de esta manera permitir el mayor número de opciones en igualdad de condiciones, en procura de consolidar la satisfacción del interés general a partir de la selección de la mejor opción de acuerdo con los intereses del Estado.

Estos principios solo se garantizarán si se permite la inclusión en el proceso de selección de todas las personas naturales o jurídicas que se consideren con las capacidades necesarias para cumplir con el objeto de un determinado contrato.

En espera de haber aclarado sus inquietudes.

Cordialmente.

**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
CAMACOL – Presidencia Nacional**